

1500858-14.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes

constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500858-14.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500858-14.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2162298/2021 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 18521398 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 3315/21/516 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2162298 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2162298/2021 -

DEL.SEC.TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 10, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, na noite de 15 de junho de 2021, por volta das 21h20m, inicialmente na Rua Hilda Corrêa de Moura, Bairro Jardim Oásis, e ulteriormente na residência situada na Rua Ciro Carlos de Oliveira Garcez no 84, Bairro Bonfim, nesta cidade e comarca, constatou-se que trazia e guardava consigo, respectivamente, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, noventa e três gramas e noventa e seis centigramas (93,96 g), aproximadamente, da droga cannabis sativa L - maconha (tetrahydrocannabinol - THC) e dez gramas e doze centigramas (10,12g) do entorpecente cocaína, substâncias estas determinantes de dependência física e psíquica, consoante testificam o auto de constatação e o laudo de exame químico toxicológico acostados nos autos.

Consta na denúncia que as drogas apreendidas em poder do réu destinavam-se à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade, forma de apresentação e

variedade, assim como do horário e local da primeira apreensão (na via pública, durante a noite).

Conforme a exordial, encontrava-se o réu no primeiro local supracitado na posse - no interior de sacola que tinha consigo - de quarenta e cinco (45) invólucros contendo setenta e um gramas e trinta e três centigramas (71,33 g) do estupefaciente maconha, vinte e quatro (24) unidades da cocaína em sua forma compacta (pedras de crack), contendo quatro gramas e setenta centigramas (4,70 g) da substância ilícita, e onze (11) envoltórios deste mesmo narcótico em sua forma pura e natural (pó branco de granulometria fina), contendo cinco gramas e quarenta e dois centigramas (5,42 g) deste malsinado produto, estando todas as embalagens repartidas e preparadas em porções individuais para a venda no varejo, sendo estas drogas apreendidas em poder do réu por ocasião de patrulhamento policial de rotina efetuado no local, oportunidade em que ele arremessou no solo a sacola na qual carregava os estupefacientes ao perceber a iminência da abordagem policial. Versa a inicial que, em diligência policial posterior imediatamente realizada no domicílio do réu (segundo local acima citado), verificou-se que ele ali guardava (em sacola depositada na garagem da residência), para a consecução do vil comércio de drogas, outros dezessete (17) invólucros contendo vinte e dois gramas e sessenta e três centigramas (22,23 g) de maconha, distribuídos em porções, os quais igualmente se destinavam, pela sua quantidade e forma de apresentação, ao comércio ilícito.

Após o oferecimento da denúncia (fls. 73/74), o réu foi devidamente notificado (fls. 85/86) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 90).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 91/92) e o réu foi regularmente citado (fls. 107/108).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público, requereu a condenação do réu, salientando a confissão, a prova testemunha e pericial. Regime fechado, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade.

Já a Defesa requereu, diante da confissão, que seja considerada a confissão do réu e aplicado o redutor, com o consequente regime aberto e substituição da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/29), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo do exame de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 23/26), pela fotografia do réu (fls. 28), pela fotografia dos entorpecentes apreendidos (fls. 29), pelo exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias Cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos (fls. 66/68), e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, em solo policial (fls. 06), informou que "dispensa a assistência de Advogado para este ato, contudo, afirma não dispor de recursos para custear o trabalho de um defensor e, por tal razão requer lhe seja concedido um defensor público; afirma que seus familiares, em especial sua própria genitora estão cientificados de sua prisão e lhe prestam assistência neste ato; afirma não ter sofrido violência de espécie alguma por parte dos policiais que lhe prenderam; quanto aos fatos ora apurados, afirma que acerca de um mês foi aliciado para vender drogas; afirma não saber informar o nome de seus fornecedores; afirma que a droga é deixada enterrada nas proximidades do local onde foi abordado; afirma que desenterra as drogas e, a cada lote de 13 papelotes ou ependorfs, três é o seu próprio ganho fazendo a retirada imediata e o restante do dinheiro aferido com a venda, enterra novamente no mesmo local para que posteriormente seja arrecadado pelo fornecedor; afirma que nesta data se encontrava no local dos fatos com sua bicicleta, quando viu a aproximação

dos policiais e, como havia acabado de desenterrar a sacola com as drogas que venderia nesta data, tentou dispensar a sacola, contudo foi flagrado e detido pelos policiais; afirma que durante a abordagem confessou que em sua residência tinha mais uma pequena quantidade de invólucros de MACONHA, indicando o local onde poderia ser encontrada; afirma que sua bicicleta foi deixada pelos policiais em sua residência, aos cuidados de sua genitora" (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Fernando disse que tem 21 anos, trabalha com o pai de um amigo na feira, foi preso quando menor, por roubo. Fumava maconha, mas está parando. Estava subindo a pracinha com a droga, perdeu o serviço, pegou a droga no terreno enterrado, primeira vez que fez isso, foi abordado na pracinha. Perguntaram se tinha mais droga, falou que tinha. Era o primeiro dia que ia vender droga. Era tudo envelope para vender por dez reais. A droga que estava na sua casa já tinha, era para o seu uso. Comprou um caroço de maconha e fez buchas. Comprou com as mesmas pessoas que entregaram a droga para ele vender. Já tinha pago. A droga enterrada tinha que vender para pagar. Não fazia um mês, foi a primeira vez. Realmente a cada 13, ficava com 3. Falou para os policiais que estava indo para o ponto para vender. A da sua casa, inicialmente falou que estava no quartinho, tinha esquecido. Fez apenas uma audiência, quando menor.

As testemunhas Fabio e Oesley, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 15 e 17), informaram que "procediam patrulhamento pelo Bairro Jd. Oazis quando, ao trafegarem pela Rua Hilda Correa de Moura, lograram visualizar a pessoa que mais tarde foi identificado como sendo FERNANDO HENRIQUE DA SILVA conduzindo uma bicicleta e, ao avistar as motocicletas da polícia militar, adotou conduta suspeita, dispensando no chão uma sacola plástica de cor cinza, conduta esta que motivou sua imediata abordagem e revista pessoal, ocasião em que apenas foi localizado um aparelho de telefone celular da marca MOTOROLA e, imediatamente foi arrecadado a sacola plástica e, constatado que no interior desta haviam quarenta e cinco invólucros de MACONHA, onze ependorfs de COCAÍNA e vinte e quatro invólucros de CRACK, drogas estas que imediatamente confessou ser de sua responsabilidade e, que acabara de desenterrar, não indicando o local onde se encontrava enterrado, afirmando apenas que venderia o entorpecente e, questionado se teria mais algum entorpecente em sua residência, respondeu que teria, afirmando inicialmente que teria outra porção de invólucros de MACONHA em um quarto de sua residência, indicando sua moradia como sendo na Rua Ciro Carlos de Oliveira Garcez nº. 84, Bonfim, nesta cidade, para onde procederam deslocamento e, no local dos fatos, foram atendidos pela genitora de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, a pessoa da Sra. JOICE MATIAS, a qual franqueou a entrada na residência, ocasião em que, a pessoa de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA afirmou que a droga não se encontrava no quarto, como anteriormente informara, mas em uma sacola plástica no canto da garagem próximo ao portão, sendo então localizada uma sacola plástica de cor preta e, no interior desta outros dezessete invólucros contendo MACONHA, razões e motivos pelos quais deram voz de prisão para a pessoa de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, ocasião em que foi deixado a bicicleta que estava em poder deste, na posse de sua genitora em sua residência" (sic).

Em juízo o policial militar Oesley disse que o réu passava de bicicleta pela praça e ao ver a equipe dispensou uma sacola. Foi abordado e no local foi localizado crack, maconha e cocaína. Com ele, um aparelho celular. Ele disse que tinha droga na casa dele. O endereço era próximo. Com a autorização da genitora dele, foi vistoriado. Mas lá ele disse que não era no quarto, mas perto do portão. Acharam perto do portão. Inicialmente ele confessou que fazia o tráfico ali e que as drogas estavam enterradas. Eram dezenas. Não se recorda números exatos. Disse que tinha acabado de desenterrar e estava levando para o Bonfim para vender. Ele começou a colaborar quando mostraram a sacola para ele. Não quis dizer de onde desenterrou a droga. Na casa inicialmente falou que era no quarto, depois disse que era perto do portão, que foi onde acharam. Estava embrulhado, mas não enterrado.

Em juízo o policial militar Fabio disse que viram o réu de bicicleta e viram perfeitamente quando dispensou um invólucro e continuou pedalando. Retornou ao

local em que ele dispensou o objeto e encontrou uma sacola plástica e em seu interior cocaína, crack, maconha, devidamente embalados para a venda. Ele admitiu que tinha acabado de desenterrar aquela droga e estava levando para um local para vender. Informou que no quarto em que dormia teria mais maconha. Na residência falaram com a genitora dele sobre o que ele disse, ela prontamente entrou com eles, mas durante a busca ele mudou o local, disse que estava na entrada da casa, para o lado de dentro do portão, foi justamente onde acharam mais porções de maconha, iguais as que estavam com ele. Estava tudo embalado. Ele admitiu a posse e a finalidade mercantil. Não conhecia o réu.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina e se depararam com o réu conduzindo uma bicicleta, o qual, ao avistar os militares, dispensou uma sacola plástica no chão, comportamento que levantou suspeitas e ensejou a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado consigo, apenas um aparelho celular. Todavia, ao resgatarem a sacola dispensada pelo réu, encontraram 45 (quarenta e cinco) invólucros de maconha, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, e 11 (onze) microtubos contendo cocaína.

Indagado pelos policiais, ele confessou informalmente a posse das drogas para fins de tráfico, relatando que havia acabado de desenterrá-las em local não identificado.

Disse que sua intenção era vender os entorpecentes e, ainda, confessou aos agentes de segurança pública que possuía mais uma porção de maconha guardada em sua casa. Então informou o endereço de sua residência, para onde os policiais se deslocaram e, lá estando, após terem a entrada franqueada pela genitora do réu, encontraram uma sacola plástica contendo mais 17 unidades de maconha, embaladas individualmente, prontas para a comercialização.

Em solo policial, o réu confessou a prática delitiva e a intenção de comercializar a droga apreendida. Relatou também que há aproximadamente um mês havia sido aliciado para vender drogas, alegando, todavia, não saber informar o nome de seus fornecedores.

Para cumprir com seu intento, ainda explicou a forma como se dava o funcionamento da empreitada criminosa: inicialmente as drogas eram enterradas nas proximidades do local onde foi abordado. Então, ele as desenterrava para proceder à venda.

Após as comercializações, ele também enterrava o restante das drogas, juntamente com o dinheiro auferido, para que fosse posteriormente arrecadado pelo fornecedor. Cabe salientar que a cada lote de treze papелotes ou eppendorfs, três eram destinados aos próprios ganhos do réu.

Em juízo, igualmente confessou a prática delitiva.

Confirmou que a droga encontrada na sacola era sua e se destinava à venda. Também que estava enterrada e que de cada 13 porções, 3 seriam suas.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

Como se pode perceber, os militares apresentaram versões firmes e coesas, indicando a forma como encontraram drogas na sacola plástica dispensada pelo réu, bem como informando que sua genitora autorizou a entrada deles na residência, ocorrida em diligência posterior.

É fato que existe no espectro jurisprudencial corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecentes.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa.

Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

No presente caso, o réu não apenas confessou, mas confirmou integralmente a narrativa policial.

Portanto, a autoria delitiva está clara.

Não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

A droga apreendida foi analisada em perícia técnica que reconheceu a ilicitude da substância, porquanto o laudo indicou que se tratava de cocaína (em sua forma pura, em pó de granulometria fina e na sua forma derivada, compactada) e Tetrahydrocannabinol (fls. 66/68).

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu transportava e tinha em depósito drogas, sendo desnecessário ter sido o réu flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câmara. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (5,42g de cocaína em sua forma pura – pó branco de granulometria fina, 4,70g de cocaína em sua forma derivada compactada, popularmente conhecida como crack, 93,96g de maconha), a forma de acondicionamento (distribuídas em 11 microtubos contendo cocaína, 24 embalagens individuais contendo pedras de crack, 62 embalagens individuais contendo maconha), as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais em patrulhamento pelo local, que avistaram o réu conduzindo uma bicicleta e no momento em que ele percebeu a presença dos policiais, descartou sacola plástica contendo droga que trazia consigo, levantando suspeita) e a própria confissão judicial evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

Na delegacia o réu havia dito que traficava há um mês, conluiado com outras pessoas. Todavia, em juízo, disse que era o primeiro dia que fazia isso, porque estava sem serviço.

Não era conhecido no meio policial. É primário e não ostenta antecedentes desabonadores, nem mesmo quando menor.

Deste modo, faz jus ao redutor do § 4.º do artigo 33.

Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 48 e 50). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente. Portanto, considerando a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas (cocaína em forma de crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas, o que aumenta a culpabilidade do agente e as consequências dos delitos), bem como a variedade das drogas apreendidas (visto que foram apreendidos maconha, cocaína e crack), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar

entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, ficando em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A exasperação da pena-base se mostra necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENALIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa” (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida” (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, minoro a reprimenda do réu em 1/5, retornando a pena ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausentes causas de aumento e, em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de que vinha traficando há tempos, reduzo a reprimenda em 2/3, o que resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são de todo desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo

juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, c.c. o §3º, pois é de se considerar a variedade de droga por ele traficada (maconha, cocaína e crack) e a natureza deletéria do crack, o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, devendo iniciar o cumprimento da pena em regime mais severo.

A fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta é idôneo quando baseado nas circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e levando-se em consideração, ainda, com preponderância sobre o referido dispositivo, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (Lei 11.343/06, art. 42).

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

"O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga" (AgRg no HC 513455/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgInt no AREsp 1503628/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 499603/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2019; HC 505557/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019; AgRg no RESp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, QUE NÃO É TÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INCIDÊNCIA EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 8. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, bem como para obstar a respectiva substituição por penas restritivas de direitos. 9. Na espécie, a razoável quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida apenas justifica o regime intermediário, na medida em que o paciente é primário e a condenação foi reduzida para patamar que não excede 4 anos de reclusão" (STJ, HC n. 451.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06/11/2018 - destaquei).

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, filho de Fabio Henrique da Silva e Joice Matias, RG n.º 55.957.436, nascido aos 21 de janeiro de 2001, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da

execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Quanto ao celular que remanesce apreendido (fls. 20/21), caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123 do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberados para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio, ou ainda para recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA